

1521220-43.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou. 5.1. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521220-43.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521220-43.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WELLINGTON AUGUSTO DA SILVA BACINELLO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

WELLINGTON AUGUSTO DA SILVA BACINELLO (RG: 32650380/SP) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal 11.343/06, e no artigo 333 do Código Penal, em concurso material, ambos c.c artigo 61, inciso II, j, do Código Penal: porque no dia 02 de setembro de 2021, por volta das 17h, em período de calamidade pública, na Rua Rio Madeira, n.º 20, Cidade Dutra, nesta cidade e Comarca, teria em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 29 (vinte e nove) sacos contendo cocaína com peso líquido de 793,5 (setecentos e noventa e três gramas e cinco decigramas), 01 (um) pacote contendo cocaína com peso líquido de 989,2 (novecentos e oitenta e nove gramas e dois decigramas), 17 (dezessete) sacos contendo maconha com peso líquido de 1.875,9 (mil oitocentos e setenta e cinco gramas e nove decigramas), 125 (cento e vinte e cinco) potes contendo substância entorpecente skunk, sujeita à confirmação em laudo definitivo com peso líquido de 70,9 (setenta gramas e nove decigramas), 84 (oitenta e quatro) porções contendo maconha com peso líquido de 69,7 (sessenta e nove gramas e sete

decigramas), 3 (três) tijolos contendo maconha com peso líquido de 2.804,5 (dos mil oitocentos e quatro gramas e cinco decigramas) e 426 (quatrocentos e vinte e seis) pedras de "crack" com peso líquido de 140,9 (cento e quarenta gramas e nove decigramas); e porque, nas mesmas circunstâncias de local e data supracitadas, teria oferecido vantagem indevida aos policiais militares Gerson Gomes de Carvalho Junior e Patrícia Silva Santos para determiná-los a omitir ato de ofício, consistente na sua prisão em flagrante.

O acusado foi preso em flagrante (fls. 06/07) e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 53/58).

O réu foi citado (fls. 106) e apresentou defesa prévia (fls. 109/110) e a denúncia foi recebida (fls. 112).

Durante a primeira audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas policiais e a Defesa requereu a substituição da testemunhas por ela arroladas, a serem qualificadas.

Durante a audiência em continuação, foi ouvida a testemunha de defesa. Ao final, houve interrogatório do réu.

O Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, com aumento da pena base em razão da quantidade de drogas, o agravamento pela reincidência, e a fixação do regime inicial fechado.

A Defesa requereu a absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal; o afastamento da agravante da calamidade pública; a fixação de regime diverso do fechado; a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

O laudo químico-toxicológico definitivo comprova que as drogas apreendidas em posse do acusado eram: 29 (vinte e nove) sacos com peso líquido de 793,5 (setecentos e noventa e três gramas e cinco decigramas) e 01 (um) pacote com peso líquido de 989,2 (novecentos e oitenta e nove gramas e dois decigramas), contendo cocaína; além de 17 (dezessete) sacos com peso líquido de 1.875,9 (mil oitocentos e setenta e cinco gramas e nove decigramas), 84 (oitenta e quatro) porções com peso líquido de 69,7 (sessenta e nove gramas e sete decigramas) e 3 (três) tijolos com peso líquido de 2.804,5 (dois mil oitocentos e quatro gramas e cinco decigramas), contendo maconha; bem como 426 (quatrocentos e vinte e seis) pedras de "crack" com peso líquido de 140,9 (cento e quarenta gramas e nove decigramas) e 125 (cento e vinte e cinco) potes com peso líquido de 70,9 (setenta gramas e nove decigramas), contendo a substância ADB-Butinaca.

As testemunhas policiais Gerson Gomes de Carvalho Junior e Patrícia Silva Santos, em sede policial, declararam que estavam realizando patrulhamento, no interior da favela denominada "Vila da Paz", com a finalidade de localizar os indivíduos envolvidos na prática de tentativa de roubo à escolta do Prefeito, a partir de denúncia anônima (W2109020232). Disseram que ao adentrarem numa das estreitas vielas da comunidade, depararam-se com um indivíduo saindo de uma porta que, quando avistou a guarnição, assustou-se e tentou retornar rapidamente para o interior do imóvel. Contaram que em virtude da atitude suspeita, avançaram em direção à porta que permaneceu aberta, momento em que o indivíduo, ao ser visualizado, passou a dizer "perdi senhor, perdi senhor". Relatou que no mesmo contexto, constataram, de imediato, que o imóvel se tratava, na verdade, de um depósito, uma vez que não havia nenhum móvel usualmente existente em uma moradia, bem como a presença de duas malas de viagem próximos da porta, além de um forte odor característico de entorpecente - maconha. Disseram que foi identificado o indivíduo como sendo WELLINGTON AUGUSTO DA SILVA BACINELLO, o qual, por sua vez, após indagado a respeito do seu comportamento nervoso com a presença policial, declarou, de pronto, que as malas armazenavam drogas e que o imóvel era utilizado como "casa bomba", em referência ao local usualmente utilizado para depósito de drogas. Em prosseguimento, narram que verificaram, de fato, as malas armazenavam expressiva quantidade de substâncias aparentando ser entorpecentes, tais como, cocaína, maconha e crack. Além disso, informaram que localizaram a quantia de R\$ 1.775,50, em diversas cédulas, no interior de uma das malas. Nessas circunstâncias,

asseveraram que WELLINGTON AUGUSTO DA SILVA BACINELLO questionou “tem ideia pra trocas, senhor?” e, na sequência, disse “tenho R\$ 15 mil para liberar eu”, sendo imediatamente conduzido à delegacia.

Em juízo, a testemunha policial Gerson afirmou que houve uma tentativa de roubo na casa do prefeito e, pelo disque-denúncia, falaram que um dos possíveis roubadores estaria na comunidade da Vila da Paz. Informou ter ido no local, junto com outras equipes, e a pé acessou uma das vielas estreitas, vendo o acusado saindo de uma porta de madeira. Relatou ter o acusado visto a equipe policial e tentou recuar, mas o declarante conseguiu deter o denunciado. Contou que a porta estava aberta e exalava um odor característico de entorpecentes. Informou ter o acusado falado que “perdeu, perdeu” e falou sobre os entorpecentes, oferecendo R\$ 15.000,00 para os policiais com o objetivo de soltar o réu. Narrou que tinham duas bolsas no local com drogas e R\$ 1.100,00. Destacou que o cubículo onde foram encontradas as drogas era uma “casa bomba”. Relatou terem encontrado duas balanças e embalagens para condicionar entorpecentes. Contou que três policiais participaram da ocorrência do prefeito e no local do flagrante havia mais de cinco equipes policiais. Informou que tem um “cingapura” perto do local. Informou que a policial Patrícia e outro colega viram a abordagem. Disse que teve participação de emissoras de TV como a Bandeirantes. Afirmou não ter visto o valor de R\$ 15.000,00. Informou que a agente policial presenciou o oferecimento do dinheiro pelo denunciado.

A testemunha policial Patrícia afirmou que receberam uma denúncia que um dos indivíduos que tentaram roubar a escolta do prefeito estava escondida na comunidade da Vila da Paz. Relatou ter ido com várias equipes com a participação de uma emissora de TV no local dos fatos. Contou que, ao entrar numa viela, o tenente à frente viu o indivíduo abrindo uma porta e tentou voltar. Disse que conseguiram ver as malas no chão e sentiu o forte odor. Contou ter o acusado falado “perdeu, perdeu”. Informou terem verificado que era um depósito. Disse que dentro das malas foram encontradas drogas. Asseverou ter o acusado oferecido o valor para os policiais. Informou que o local é uma viela estreita. Relatou que não havia imóveis no local. Narrou ter encontrado dinheiro, algumas drogas já embaladas e balanças. Contou que o acusado ofereceu dinheiro para o tenente e também para a declarante. Informou que estavam em três policiais. Destacou ter o acusado oferecido R\$ 15.000,00 e depois foi aumentando o valor. Relatou que o programa do Datena estava transmitindo a operação policial. Informou que as drogas estavam em bolsas de viagem.

Em juízo, a testemunha de defesa Taynara da Silva Santos narrou que chegou a ver a abordagem do réu pela polícia, já que estava na quadra, onde sua filha estava brincando. Disse que viu o réu passando, entrando numa viela e os policiais o abordaram. Esclareceu que subiu então para seu apartamento com a filha no colo e ao entrar no seu apartamento, viu pela janela que ele estava sentado no chão e algemado. Falou que não viu ele com nada nas mãos. Aduziu que os PMS estavam a pé na viela, mas que tinha ROCAM no estacionamento quando passou pela viela. Explicou que, assim que o réu entrou na viela, os PMS saíram de uma casa, o abordou e ele parou. Disse que havia mais pessoas na quadra, pois é muito movimentada. Asseverou que ele foi abordado em frente do Bar da Loira, perto da casa de onde saíram os policiais. Relatou que viu o momento em que o réu foi abordado, pois estava passando na viela naquele momento para ir para sua casa, mas não parou para ficar olhando, e quando entrou no seu apartamento, viu, pela janela, que ele já estava algemado no estacionamento. Disse que a viela estava vazia, então acha que só ela presenciou. Falou que a casa de onde saíram os policiais fica duas casas do lado do bar e não conhece quem reside ali. Também falou que conhece o réu de vista. O acusado, em seu termo de interrogatório extrajudicial, em sede policial, permaneceu em silêncio.

Em juízo, o réu negou os fatos, pois nesse dia estava trabalhando e por volta das 4 da tarde, não podia fazer barulho, então já estava indo buscar sua esposa na padaria. Falou que estacionou o carro, andou alguns passos e, passando na viela, já encontrou dois policiais de frente, que o abordaram e o retiraram da viela, e para quem informou que já tinha passagem por crimes anteriores, mas não devia mais nada. Relatou que, após alguns minutos, outros policiais saem da viela, chamou um dos

policiais que estavam com ele, e ele ouviu “esse aqui serve”. Narrou que o algemaram e levaram para dentro da viela, parando na frente de uma casa. Falou que, à noite, o colocaram na viatura sem informá-lo porque estava sendo levado, dizendo que ele era a “laranja da vez”. Asseverou que, na delegacia, não falou com ninguém, e só às 3 horas da manhã foi chamado e informado pelo delegado a razão de ter sido preso. Aduziu que falou ao delegado que não tinha ciência das malas que alegaram ser sua e foi orientado a não falar nada na delegacia. Relatou que, em nenhum momento correu ou ameaçou correr, nem ter sido violento contra os policiais. Respondeu que o local da abordagem é perto onde reside, que a casa onde foram encontradas as drogas fica em torno de 1 km de distância da sua casa. Explicou que a sua esposa trabalha ali perto, quase de frente, numa padaria, a uns 200 metros de onde foi abordado. Falou que há várias vielas e que no local onde foi abordado há umas 3 entradas. Esclareceu que, na ocasião da abordagem, dois policiais o abordaram, depois vieram mais três, um dos quais era uma policial, e ao final chegaram muito mais policiais. Falou que só a noite teve a dimensão da operação, pois havia umas 10 viaturas, inclusive a ROCAM. Explicou que o policial Gerson o abordou, depois a policial Patrícia saiu da viela, com outros dois policiais, que conversaram com Gerson e falaram “esse aqui serve”. Disse que ela foi quem o levou à delegacia. Respondeu que, por diversas vezes, pediram para baixar a cabeça para não mostrar o rosto para a reportagem presente no local, mas percebeu que filmaram seu rosto umas duas vezes. Falou que viu o repórter na entrada da viela. Aduziu que, da abordagem até a casa dá uns 100 a 150 metros. Alegou que não estava em dentro de casa ou tentou entrar em alguma casa.

Pelo que se depreende dos autos, havia em andamento uma investigação relacionada a uma tentativa de roubo à escolta do Prefeito e uma grande operação foi montada na tentativa de capturar os envolvidos. Primeiramente, cumpre destacar que foi uma operação que violou o princípio da impessoalidade, já que movida por interesses particulares em detrimento do interesse público, em especial daquela comunidade, onde pessoas foram abordadas sozinhas ou em grupos, e muitas vielas foram revistadas. Contudo, o fato que interessa é que os policiais informaram que o réu estava numa residência e, ao abrir a porta, se deparando com os agentes, retornou para dentro do imóvel. Essa atitude não foge do que se espera de qualquer pessoa comum, pois se um morador se depara com policiais na porta de sua casa e há riscos de haver tiroteios, é normal fechar a porta e retornar para dentro da residência. Isso não dá respaldo para que a polícia invada a sua casa. Não era esse o caso do presente feito, ao que parece. Mas o fato é que os policiais entraram no imóvel onde não se permitia o ingresso sem autorização. Foi esse o tipo de situação que levou o Superior Tribunal de Justiça a tomar a decisão recente contra violação de domicílio. Para que houvesse a devida apreensão das drogas naquele imóvel, os policiais deveriam ter a devida autorização por meio de um mandado de busca e apreensão. Não foi o que aconteceu.

Nesse sentido, o ingresso dos policiais no imóvel sem autorização judicial ou sem a prova do consentimento do morador, torna ilegal tudo que foi encontrado e, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada, são nulas todas as provas derivadas do encontro das drogas, não sobrando, portanto, mais nada que incrimine o réu.

Nesse sentido, já decidiu o referido Tribunal:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. VERSÃO NEGADA PELA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. PROVA ILÍCITA. NOVO ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA HC 598.051/SP. VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DEPENDE DE PROVA ESCRITA E GRAVAÇÃO AMBIENTAL. WRIT NÃO CONHECIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso XI, estabelece

que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 3. Em recente julgamento no HC 598.051/SP, a Sexta Turma, em voto de relatoria do Ministro Rogério Schietti - amparado em julgados estrangeiros -, decidiu que o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e, ainda, for registrado em gravação audiovisual. 4. O eminente Relator entendeu ser imprescindível ao Judiciário, na falta de norma específica sobre o tema, proteger, contra o possível arbítrio de agentes estatais, o cidadão, sobretudo aquele morador das periferias dos grandes centros urbanos, onde rotineiramente há notícias de violação a direitos fundamentais. 5. Na hipótese em apreço, consta que o paciente e a corré, em razão de uma denúncia anônima de tráfico de drogas, foram abordados em via pública e submetidos a revista pessoal, não tendo sido nada encontrado com eles. Na sequência, foram conduzidos à residência do paciente, que teria franqueado a entrada dos policiais no imóvel. Todavia, a defesa afirma que não houve consentimento do morador e, na verdade, ele e sua namorada foram levados à força, algemados e sob coação, para dentro da casa, onde foram recolhidos os entorpecentes (110g de cocaína e 43g de maconha). 6. Como destacado no acórdão paradigma, "Essa relevante dúvida não pode, dadas as circunstâncias concretas - avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência cotidiana do que ocorre nos centros urbanos - ser dirimida a favor do Estado, mas a favor do titular do direito atingido (in dubio libertas). Em verdade, caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento do morador." 7. Na falta de comprovação de que o consentimento do morador foi voluntário e livre de qualquer coação e intimidação, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade na busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). 8. Vale anotar que a Sexta Turma estabeleceu o prazo de um ano para o aparelhamento das polícias, o treinamento dos agentes e demais providências necessárias para evitar futuras situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, resultar em responsabilização administrativa, civil e penal dos policiais, além da anulação das provas colhidas nas investigações. 9. Fixou, ainda, as seguintes diretrizes para o ingresso regular e válido no domicílio alheio, que transcrevo a seguir:

"1. Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 2. O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada. 3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. 4. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo. 5. A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência."

10. Habeas corpus não conhecido. Ordem, concedida, de ofício, para declarar a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar, e todas as dela

decorrentes, na AP n. 132/2.20.0001682-3. Expeçam-se, também, alvará de soltura em benefício do paciente e, nos termos do art. 580 do CPP, da corrê.
(STJ. HC: 616.584 – RS. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Julgado no dia 30 de março de 2021) (Grifo nosso)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na companhia de seu grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exige. 1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Célebre, a propósito, a exortação de Conde Chatham, ao dizer que: "O homem mais pobre pode em sua cabana desafiar todas as forças da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar, mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!" ("The poorest man may in his cottage bid defiance to all the forces of the Crown. It may be frail, its roof may shake, the wind may blow through it, the storm may enter, the rain may enter, but the King of England cannot enter!" William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March 1763, in Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the Time of George III First Series (1845) v. 1). 2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legítima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8º), que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor instrumentalização da investigação – e, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio – justificam o retardo da cessação da prática delitiva. 2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação – amiúde irreversível – de todo o processo, em prejuízo da sociedade. 3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Em conclusão a seu voto, o relator salientou que a interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a tal medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de assumir o risco de

cometer crime de invasão de domicílio ou de abuso de autoridade, principalmente quando a diligência não tiver alcançado o resultado esperado. 4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente. 5. Se, por um lado, práticas ilícitas graves autorizam eventualmente o sacrifício de direitos fundamentais, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e devassada, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou. 5.1. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. 5.2. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos - diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas - pode fragilizar e tornar irritado o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar, a qual protege não apenas o suspeito, mas todos os moradores do local. 5.3. Tal compreensão não se traduz, obviamente, em cercear a necessária ação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de entorpecentes, muito menos em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos ou em espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso policial no domicílio alheio a situação de ocorrência de um crime cuja urgência na sua cessação desautorize o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial - meio ordinário e seguro para o afastamento do direito à inviolabilidade da morada - legitimar a entrada em residência ou local de abrigo. 6. Já no que toca ao consentimento do morador para o ingresso em sua residência - uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da República para o afastamento da inviolabilidade do domicílio - outros países trilharam caminho judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis, geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso alheio. 6.1. Nos Estados Unidos, por exemplo, a par da necessidade do exame da causa provável para a entrada de policiais em domicílio de suspeitos de crimes, não pode haver dúvidas sobre a voluntariedade da autorização do morador (*in dubio libertas*). O consentimento "deve ser inequívoco, específico e conscientemente dado, não contaminado por qualquer truculência ou coerção (*"consent, to be valid, 'must be unequivocal, specific and intelligently given, uncontaminated by any duress or coercion'*"). (*United States v McCaleb*, 552 F2d 717, 721 (6th Cir 1977), citando *Simmons v Bomar*, 349 F2d 365, 366 (6th Cir 1965). Além disso, ao Estado cabe o ônus de provar que o consentimento foi, de fato, livre e voluntariamente dado, isento de qualquer forma, direta ou indireta, de coação, o que é aferível pelo teste da totalidade das circunstâncias (*totality of circumstances*). 6.2. No direito espanhol, por sua vez, o Tribunal Supremo destaca, entre outros, os seguintes requisitos para o consentimento do morador: a) deve ser prestado por pessoa capaz, maior de idade e no exercício de seus direitos; b) deve ser consciente e livre; c) deve ser documentado; d) deve ser expresso, não servindo o silêncio como consentimento tácito. 6.3. Outrossim, a documentação comprobatória do assentimento do morador é exigida, na França, de modo expresso e mediante declaração escrita à mão do morador, conforme norma positivada no art. 76 do Código de Processo Penal; nos EUA, também é usual a necessidade de assinatura de um formulário pela pessoa

que consentiu com o ingresso em seu domicílio (North Carolina v. Butler (1979) 441 U.S. 369, 373; People v. Ramirez (1997) 59 Cal.App.4th 1548, 1558; U.S. v. Castillo (9a Cir. 1989) 866 F.2d 1071, 1082), declaração que, todavia, será desconsiderada se as circunstâncias indicarem ter sido obtida de forma coercitiva ou houver dúvidas sobre a voluntariedade do consentimento (Haley v. Ohio (1947) 332 U.S. 596, 601; People v. Andersen (1980) 101 Cal.App.3d 563, 579. 6.4. Se para simplesmente algemar uma pessoa, já presa – ostentando, portanto, alguma verossimilhança do fato delituoso que deu origem a sua detenção –, exige-se a indicação, por escrito, da justificativa para o uso de tal medida acautelatória, seria então, no tocante ao ingresso domiciliar, “necessário que nós estabeleçamos, desde logo, como fizemos na Súmula 11, alguma formalidade para que essa razão excepcional seja justificada por escrito, sob pena das sanções cabíveis” (voto do Min. Ricardo Lewandowski, no RE n. 603.616/TO). 6.5. Tal providência, aliás, já é determinada pelo art. 245, § 7º, do Código de Processo Penal – analogicamente aplicável para busca e apreensão também sem mandado judicial – ao dispor que, “[f]inalda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4º”. 7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país conhecido por suas práticas autoritárias – não apenas históricas, mas atuais –, a aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça. 7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação – como ocorreu no caso ora em julgamento – de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade. 7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral – pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro – e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado. 8. Ao Poder Judiciário, ante a lacuna da lei para melhor regulamentação do tema, cabe responder, na moldura do Direito, às situações que, trazidas por provocação do interessado, se mostrem violadoras de direitos fundamentais do indivíduo. E, especialmente, ao Superior Tribunal de Justiça compete, na sua função judicante, buscar a melhor interpretação possível da lei federal, de sorte a não apenas responder ao pedido da parte, mas também formar precedentes que orientem o julgamento de casos futuros similares. 8.1. As decisões do Poder Judiciário – mormente dos Tribunais incumbidos de interpretar, em última instância, as leis federais e a Constituição – servem para dar resposta ao pedido no caso concreto e também para “enriquecer o estoque das regras jurídicas” (Melvin Eisenberg. The nature of the common law. Cambridge: Harvard University Press, 1998. p. 4) e assegurar, no plano concreto, a realização dos valores, princípios e objetivos definidos na Constituição de cada país. Para tanto, não podem, em nome da maior eficiência punitiva, tolerar práticas que se divorciam do modelo civilizatório que deve orientar a construção de uma sociedade mais igualitária, fraterna, pluralista e sem preconceitos. 8.2. Como assentado em conhecido debate na Suprema Corte dos EUA sobre a admissibilidade das provas ilícitas (Weeks v. United States, 232 U.S. 383, 1914), se os tribunais permitem o uso de provas obtidas em buscas ilegais, tal procedimento representa uma afirmação judicial de manifesta

negligência, se não um aberto desafio, às proibições da Constituição, direcionadas à proteção das pessoas contra esse tipo de ação não autorizada ("such proceeding would be to affirm by judicial decision a manifest neglect, if not an open defiance, of the prohibitions of the Constitution, intended for the protection of the people against such unauthorized action"). 8.3. A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam a esta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social e econômico, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança. 9. Na espécie, não havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificassem a invasão de domicílio do suspeito, porquanto a simples avaliação subjetiva dos policiais era insuficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência, visto que não foi encontrado nenhum entorpecente na busca pessoa realizada em via pública. 10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, conseqüentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. 11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita – no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de maconha –, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas. 12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e conseqüente absolvição do paciente, dando-se ciência do inteiro teor do acórdão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como às Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-Geral da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a todos os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e distrital. 13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal. (STJ. HC: ° 598.051 – SP. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Julgado no dia 02 de março de 2021.)

Portanto, de rigor, o reconhecimento da ilicitude da prova, já que obtida por meio de invasão de domicílio, com a conseqüente absolvição do réu por ausência da materialidade do crime de tráfico e, por conseqüência, da corrupção ativa que, no caso, está atrelada à prisão pelo tráfico, havendo uma relação de interdependência, sem prejuízo das contradições existentes na fala dos policiais acerca da corrupção ativa.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido acusatório e, por conseqüência, nos termos do artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu WELLINGTON AUGUSTO DA SILVA BACINELLO (RG: 32650380/SP) da imputação de ter infringido o disposto no artigo 33, caput, da Lei Federal 11.343/06, e o artigo 333 do Código Penal, em concurso material, ambos c.c artigo 61, inciso II, j, do Código Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Autorizo a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas.

Considerando-se a propriedade incerta dos bens apreendidos, decreto o perdimento do valor em favor da União, por se tratar de bem provavelmente proveniente da prática de tráfico, de acordo com o art. 63 da Lei 11.343/06, assim como dos demais

objetos, autorizando-se sua destruição.

P.I.C.

São Paulo, 05 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA